

1500726-14.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... vestimenta da pessoa que realizava o tráfico no local, conforme indicado pelo transeunte que os abordou. Também declararam que viram com precisão o acusado em conduta típica de tráfico, entregando aparentemente substâncias entorpecentes a um motociclista que rapidamente deixou o local e, por fim, confirmaram que em poder do acusado estavam as drogas apreendidas, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500726-14.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000510

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118354/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 17658071 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1238/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2118354 - 02º D.P. PIRACICABA,

1238/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GUSTAVO BOMBACH DA GAMA

Aos 09 de fevereiro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: GUILHERME GUSTAVO BOMBACH DA GAMA - AUSENTE

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM MARCUS VINICIUS DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM LUCAS EMYGDIO FERNANDES - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, ante à ausência do réu, pela MM. Juíza foi dito:

"Considerando que o réu mudou de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, não tendo sido localizado para ser intimado da presente audiência, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal".

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PM MARCUS VINICIUS DA SILVA.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM LUCAS EMYGDIO FERNANDES, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM LUCAS EMYGDIO FERNANDES, o que foi homologado pela MMª. Juíza. Após, o réu GUILHERME GUSTAVO BOMBACH DA GAMA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "Guilherme Gustavo Bombach da Gama, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 148), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 152/157), sendo a denúncia recebida (fls. 158/160). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi declarado revel. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pela fotografia de fls. 18 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 123/125. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Marcus Vinicius da Silva, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando foram informados por um transeunte que havia um indivíduo realizando tráfico na rua Igaratá, informando suas características. No local indicado, já conhecido como ponto de venda de drogas, os policiais avistaram o réu, cujas características coincidiam com as informadas, e viram o momento que ele entregava algumas substâncias, aparentemente entorpecentes, ao condutor de uma motocicleta, que deixou o local rapidamente. Diante da conduta suspeita, abordaram o acusado e, em seu poder, encontraram 24 eppendorfs de cocaína, 24 invólucros de papel filme de maconha e 73 microtubos de crack, além da quantia de vinte reais. Indagado, o acusado confessou informalmente que estava realizando o tráfico de drogas no local. No mesmo sentido foram as palavras do policial militar Lucas Emydio Fernandes, ouvido apenas em fase policial. Por fim, o réu negou optou por tornar-se revel, ao invés de comparecer em Juízo e dar sua versão para os fatos. Por outro lado, é certo que os policiais ouvidos tanto na fase judicial quanto inquisitiva foram coesos ao afirmar que o réu apresentava as mesmas características de vestimenta da pessoa que realizava o tráfico no local, conforme indicado pelo transeunte que os abordou. Também declararam que viram com precisão o acusado em conduta típica de tráfico, entregando aparentemente substâncias entorpecentes a um motociclista que rapidamente deixou o local e, por fim, confirmaram que em poder do acusado estavam as drogas apreendidas, conforme descrito na denúncia. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou

conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, ante a prova oral produzida, bem como a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado e as circunstâncias em que foi ele flagrado, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, haja vista primariedade do acusado. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a ser reconhecidas. Na terceira fase, em que pese a primariedade do acusado, ante a considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 24 porções de maconha, 24 eppendorfs de cocaína e 73 microtubos de crack - tem-se ser inaplicável o art. 33, §4º da Lei de Drogas, eis que o "cardápio" diversificado de entorpecentes revela que reiterava ele na venda das drogas, fazendo desta hedionda conduta seu meio de vida, sendo certo que não esgotaria ele a venda em um só ato isolado em sua vida, muito ao contrário. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 20,00 (vinte reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Marcus Vinicius, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento quando um transeunte abordou a equipe e indicou que na rua Igaratá havia um indivíduo na prática do tráfico de drogas. Foram até o local e encontraram o réu entregando algo a um motociclista. Diante disso, fizeram a abordagem e encontraram as drogas em poder do réu. O acusado confessou informalmente que estava traficando drogas. O local também é conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Apreenderam dinheiro em poder do réu. O dinheiro estava no bolso da calça do acusado. As características do réu coincidiam com aquelas informadas na denúncia (calça escura e blusa branca). O réu não compareceu à audiência designada para sua oitiva, todavia, sua ausência não pode ser tomada em seu prejuízo, haja vista que está inserida na autodefesa do acusado a opção por deixar de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, à semelhança do direito constitucional ao silêncio. No mais, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a

longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da suposta “movimentação suspeita” visualizada, não foram apresentados outros indivíduos como eventuais compradores das substâncias entorpecentes e/ou testemunhas presenciais dos fatos, embora os próprios agentes mencionem que outras pessoas se encontravam no local. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º – Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos

legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário na época dos fatos; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da menoridade relativa; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

GUILHERME GUSTAVO BOMBACH DA GAMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 23h, na Rua Igaratá, nº 418, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 73 (setenta e três) porções de cocaína na forma de "crack", pesando cerca de 7,3 g (sete gramas e três decigramas), 24 (vinte e quatro) eppendorfs de cocaína em pó, pesando aproximadamente 7,2 g (sete gramas e dois decigramas), e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso líquido de 19,36g (dezenove gramas e trinta e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em regular patrulhamento pelo bairro local dos fatos, quando receberam informações de um transeunte, que não quis se identificar, dando conta que um indivíduo trajando moletom branco e calças escuras estaria realizando o tráfico de drogas na Rua Igaratá. Com o escopo de apurar a veracidade da denúncia, os milicianos se deslocaram até o local indicado, onde visualizaram o réu, cujas características de vestimenta coincidiam com as informadas pelo denunciante, em atividade típica de tráfico, eis que entregava algo ao condutor de uma motocicleta, o qual se evadiu ao avistar a viatura e não foi identificado. Em razão disso, os policiais abordaram o acusado e apreenderam em sua posse o entorpecente retro descrito e a quantia de R\$ 20,00 em notas trocadas.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 148) e apresentou defesa preliminar (fls. 152/157), seguindo-se a decisão de fls. 158/160, que recebeu a denúncia em 18.08.2021.

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha, prejudicado o interrogatório do réu, que se tornou revel.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pela fotografia de fls. 18 e pelo laudo de fls. 123/125, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 07/08).

Em juízo, tornou-se revel.

A prova dos autos, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o policial militar Marcus Vinicius relatou que estavam em patrulhamento

quando foram abordados por um transeunte, que falou que, na Rua Igaratá, havia um indivíduo na prática de tráfico, fornecendo suas características. Atestou que foram até o local e avistaram um indivíduo com as características informadas, entregando algo para um motociclista. Disse que se aproximaram para fazer a abordagem e o motociclista deixou o local. Então, abordaram o réu e encontraram porções de maconha, cocaína e "crack" numa sacola que ele portava, além de dinheiro, no seu bolso. Informou que não conhecia o réu anteriormente, mas o local já era conhecido como ponto de tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Lucas, ouvido a fls. 06.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem recebido denúncia da traficância no local e, logo em seguida, terem visualizado o réu no lugar indicado, cujas características físicas e de vestimentas coincidiam com os informados pelo denunciante, em atividades típicas de tráfico, vindo a localizar em seu poder 73 porções de "crack", 24 eppendorfs de cocaína, e 24 porções de maconha, além de R\$20,00 em notas trocadas, conduz à certeza quanto à autoria e a traficância.

Anoto que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidas, e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, à denúncia prévia dando conta da traficância e às circunstâncias da apreensão, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Impõe-se, portanto, a condenação a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, no valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Não há causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios do seu envolvimento com o crime organizado, razão pela qual reduza a pena em metade, nos termos do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa. Anoto que não é cabível redução maior em razão da quantidade e natureza de parte da droga apreendida (73 porções de "crack", 24 porções de cocaína e 24 porções de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Porque não comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando GUILHERME GUSTAVO BOMBACH DA GAMA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à

pena de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias -multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão a ser cumprido no regime aberto e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo DEFENSOR foi dito que aguardava a intimação do réu acerca da sentença ora proferida.

Pela MM<sup>a</sup>. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do Representante do Ministério Público, dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para a ACUSAÇÃO.

Intime-se, por edital, o réu acerca da sentença proferida.

Após, tornem conclusos para deliberações.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM<sup>a</sup>. Juíza de Direito da 4<sup>a</sup> Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]